

1502114-61.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502114-61.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502114-61.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021606/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22618904 - 02º D.P. BOM RETIRO, 206/22/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2021606 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX PESSOA RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Drª. Juliana Brescansin Demarchi Molina

Vistos.

ALEX PESSOA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 18h15, na Rua Helvetia, altura do numeral 134, bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, trazia consigo para fim de comércio, 02 invólucros contendo "maconha", com peso líquido de 3,1 gramas e 37 invólucros contendo "cocaína", com peso líquido de 23,6 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narram os autos que os policiais militares estavam em patrulhamento nas imediações da "Cracolândia" quando visualizaram o acusado e perceberam que ele carregava um

volume na região das partes íntimas.

Ao avistar os policiais o réu tentou fugir, mas foi capturado. Em busca pessoal foram localizadas as porções de drogas apreendidas e a quantia de R\$ 237,00.

O réu foi preso em flagrante delito (fl. 04), tendo sido esta convertida em prisão preventiva em decisão de fls. 71/74.

Em decisão datada de 04 de fevereiro de 2022 foi determinada a notificação do acusado para apresentar de defesa prévia (fl. 103).

O acusado foi notificado (fl. 113) e apresentou defesa preliminar (fls.119/120).

A denúncia foi recebida aos 13 de abril de 2022 (fls. 121/123). Após disponibilidade do Deecrim foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fl. 125).

O acusado foi citado em audiência.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Declarada encerrada a instrução do feito, o d. Representante do Ministério Público, em alegações finais, pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito. Quanto à dosimetria da pena, requereu a exasperação da pena base em razão dos maus antecedentes, o reconhecimento da agravante da reincidência e o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, LD. Pugnou pela fixação do regime fechado

A d. Defesa, por sua vez, sustentou a inimizabilidade do acusado, em razão da drogadição, requerendo a sua absolvição. Arguiu a figura da inexigibilidade de conduta diversa, pelo vício e pela situação de rua. No mais, alegou insuficiência de provas de autoria, sob o argumento de que a prova amealhada aos autos resume-se ao depoimento dos policiais, não sendo possível a aplicação dos efeitos da revelia na seara penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima, com o máximo redutor, mediante aplicação do parágrafo 4º da Lei 11.343/06, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, pelo laudo de constatação de fls. 26/29, indicador de que o acusado trazia consigo 02 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 3,1g (três gramas e um decigrama) e 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com massa líquida de 23,6g (vinte e três gramas e seis decigrama), além da quantia de R\$37,00 (trinta e sete reais). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 154/156, está comprovado que as substâncias apreendidas com o acusado eram "TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98" e "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil".

Posto isso, de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvido em juízo, David Costa, guarda civil metropolitano, narrou que estava em serviço quando avistou o réu saindo de dentro do fluxo da cracolância. O réu levantou suspeita por estar com um volume muito aparente por debaixo das vestes. O guarda se aproximou para perguntar o que seria o volume, mas o réu tentou correr e foi contido. Em busca pessoal, foram localizadas drogas e quantia em dinheiro. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que se tratava de uma porção considerável de cocaína e uma pequena porção de maconha. Durante a abordagem, o réu afirmou que estava carregando a droga para outra pessoa. Não conhecia o réu. Às

perguntas da Defesa, respondeu que o réu estava com vestes simples e aparentava agitação.

Em juízo, a testemunha GCM Rafael de Melo Amorim esclareceu que realiza trabalho de segurança dos agentes de saúde na área da Cracolândia, além do monitoramento do tráfico de drogas. Notou que o acusado saiu do centro do fluxo, bastante nervoso e olhando para a viatura. Ao se aproximar do acusado, ele tentou se evadir e resistir à abordagem, momento em que notou que ele trazia uma quantidade de drogas nas partes íntimas. EM revista pessoal, foram localizadas 37 porções de cocaína, 02 (duas) porções de maconha e a quantia de R\$237,00 (duzentos e trinta e sete reais). Indagado sobre as drogas e o dinheiro, o réu respondeu que estava saindo do fluxo com outra pessoa, que não foi identificada. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que no monitoramento da Guarda Civil foi identificado que o réu também fazia a venda de drogas. Acrescentou que não conhecia o réu. Às perguntas da Defesa, respondeu que, ao ser abordado, o réu disse "perdi". Sobre o monitoramento, respondeu que algumas características sobre o réu, trajando calça de moletom e camiseta, foram repassadas pela central responsável. Ciente dessas características, aliado ao nervosismo do acusado, que saía do fluxo, efetuou a abordagem.

Em solo policial, o réu negou a prática do crime. Disse que estava carregando "cocaína", para depois consumir (fl. 10).

Em juízo, disse que morava na Cracolândia e seu último trabalho foi entre os anos de 2005 e 2006. Confessou que estava transportando a droga. Alegou que é usuário de crack e foi contratado para realizar a travessia do fluxo. Às perguntas do Ministério Público, reiteradas pela Defesa, respondeu que receberia pedras de crack como pagamento. Acrescentou que, na data dos fatos, estava sob o efeito das drogas. Com efeito, a admissão de culpa é prova incontestável de autoria, somente devendo afastada quando por ela se vislumbra algum interesse escuso do confitente, o que não se verifica no caso dos autos.

Não bastasse a confissão do acusado, que admitiu estar transportando as drogas que foram encontradas consigo, o depoimento dos guardas civis que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, não se devendo desconsiderar o teor do depoimento apenas pela sua condição funcional.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por agentes de segurança, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial.

Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas.

Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)."

Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material da droga e de considerável quantia de dinheiro em espécie (aproximadamente um quarto do salário mínimo).

Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar um inocente.

Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014)."

No caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos guardas municipais, sendo cioso notar que restou incontroverso que os policiais e o réu não se conheciam anteriormente aos fatos, pelo que suas declarações merecem credibilidade.

Por oportuno, pontuo que não tem nenhuma relevância o fato de a testemunha não ter avistado o réu vendendo drogas pelo sistema de monitoramento. O crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar - sendo necessário a prática de apenas uma dessas condutas para consumir o delito em tela.

Ainda que o acusado não tenha sido flagrado durante a efetiva entrega de entorpecentes a terceiros, na tradição, deve ser condenado nos termos da imputação inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

Por fim, bem configurada a traficância, não há como acolher a tese levantada pela defesa de que o réu agiu sob o manto da dirimente consistente na exigibilidade de conduta diversa, em razão de sua drogadição, tendo em vista que, em razão da tarefa que lhe foi dada por traficante desconhecido, o réu seria recompensado com qualquer benefício que alimentaria seu vício.

Acerca do tema, ROGÉRIO GRECO conceitua a exigibilidade de conduta diversa como "a possibilidade que tinha o agente de, no momento da ação ou da omissão, agir de acordo com o direito, considerando-se a sua particular condição de pessoa humana. Cury Urzúa define a exigibilidade de conduta diversa como a 'possibilidade, determinada pelo ordenamento jurídico, de atuar de forma distinta e melhor do que aquela a que o sujeito se decidiu'".

Com efeito, para que o fato típico e ilícito não seja considerado criminoso, em uma visão tripartite do conceito analítico de crime, em virtude da excludente de culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, deve o agente, no caso concreto, não ter qualquer opção outra que não a prática da conduta tipificada pelo ordenamento jurídico, de modo a restar esvaziada a sua capacidade de autodeterminação, ou seja, de agir segundo a objeção de sua consciência.

No caso em comento, porém, o réu se valeu da prática criminosa consistente na traficância para, nas palavras da Defesa, "lhe garantir mais drogas para fazer uso". Tem-se, porém, que, ainda que comprovada a condição de dependente químico de Alex - situação que, apesar de provável, não foi objeto de competente perícia -, o delito não era prática imprescindível ao réu, sendo-lhe exigível conduta diversa da criminosa.

A tese de inexigibilidade de conduta somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostra a única alternativa possível diante de determinada situação.

E, no caso, não se pode permitir o discurso que pretenda confundir a hipervulnerabilidade social e a penúria financeira com prática criminosa,

estabelecendo falsa relação de inexorabilidade.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A remissão feita pelo Magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Precedentes do STF. 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder da ré. 3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10). 4. A existência do tipo penal reflete a implícita reprovação da sociedade à conduta desvalorada pela lei, no caso, o tráfico de drogas, que tem como bem jurídico tutelado a saúde pública. Presume-se, portanto, que o cidadão deve agir de forma diversa dos inúmeros verbos elencados no preceito primário do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. E o ônus de provar a inexigibilidade de conduta diversa, apta a afastar a reprovação que implicitamente compõe o tipo, é, indiscutivelmente, da ré. 5. Não se acolhe a tese da defesa no sentido de aplicação das chamadas "teoria da co-culpabilidade" e da "culpabilidade funcional", teorias modernistas, que se tenta inserir no Direito Penal brasileiro, fundadas no sistema funcionalista do crime, na sua vertente racional-teleológica, também conhecida como "funcionalismo moderado". Tratam-se de teorias extremamente garantistas, que visam mais a beneficiar, e mesmo fomentar, a prática de novos crimes, não impingindo as devidas punições aos agentes

criminosos, como forma de repelir novas práticas delitivas. Desta feita, não se pode conferir validade à pobreza, baixa escolaridade ou descaso do Estado para se justificar e permitir a prática de condutas penalmente tipificadas. 6. Penas mantidas conforme fixadas na Origem. 7. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ. 8. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os apetrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primordialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF. 9. Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes hediondos será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 10. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que resta afastada em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes, a demonstrar que a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos não seria suficiente para a reprovação e a prevenção do crime em comento. 11. Improvimento do recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 0003035-82.2014.8.26.0161; Relator (a): Aírton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 04/12/2015) Por esses termos, tenho que, no caso em tela, não foram produzidas provas aptas a demonstrar que a prática do crime de narcotráfico fosse a única conduta disponível para o réu, devendo ser afastada a narrativa genérica que pretende associar a situação de rua à delinquência.

De igual modo, afasto a aventada hipótese de inimputabilidade, que, presumida apenas em relação aos menores de dezoito anos, somente poderia ser caracterizada em incidente de insanidade mental, conforme a regra do art. 149 do Código de Processo Penal, medida que sequer foi pugnada pela defesa.

Ademais, na hipótese, a instauração do incidente seria incabível, porque a partir da análise do conjunto fático-probatório, inclusive após o interrogatório do acusado, constato que inexistem nos autos quaisquer dúvidas acerca da sanidade mental do réu, destacando-se que, em nenhum momento do processo, ele demonstrou qualquer deficiência mental ou distúrbio que comprometa a sua capacidade de compreensão dos fatos que lhe foram imputados.

Certa, pois, a condenação do réu nos termos da denúncia, resta, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção. Passo à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que o réu ostenta condenações anteriores transitadas em julgado. No entanto, em análise da certidão do distribuidor criminal (fls. 44/46) em conjunto com a folha de antecedentes (48/51), constato que decorreu lapso temporal superior ao período depurador entre a declaração de extinção da pena nos autos nº 0011726-81.2000.8.26.0127 (fl. 54), em 11/08/2009, e a prática do novo delito, razão pela qual deixo de valorar negativamente os maus antecedentes. De outra parte, considero desfavorável ao réu a natureza e a quantidade da droga. A cocaína é entorpecente de grande periculosidade à saúde do usuário, sendo fartos e amplamente divulgados os estudos sobre seu alto potencial viciante. Ante esse quadro, de rigor concluir que quase quatro dezenas de papелotes apreendidos, na região da Cracolândia, consubstanciavam quantidade suficiente para lesar de modo grave o bem jurídico tutelado pela norma. As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena base majorada pela fração de 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

multa.

Na segunda fase de fixação da pena, necessário que se leve em consideração que o acusado é reincidente específico, conforme evidencia a folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal juntada aos autos (processo nº 0000144-86.2017.8.26.0063 - fls. 44/45). Por outro lado, de rigor considerar que a confissão do réu, posto que qualificada, foi utilizada na fundamentação para o decreto condenatório, razão pela qual caracterizada a atenuante prevista no artigo 65, inciso II, alínea "d", do Código Penal. Assim, admitida a compensação entre uma circunstância agravante e uma atenuante, mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, quanto ao preceituado no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vejo descabida a aplicação do benefício ao acusado, uma vez que é reincidente, não sendo iniciante na seara criminal.

Nesse particular, e ao contrário do alegado pela defesa, não há bis in idem na consideração da reincidência para obstar a aplicação do privilégio. Isso porque a reincidência não é elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos elementos que obstem o aludido benefício penal, não se configurando o duplo apenamento. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: HC 393862 DF - publicado em 02.10.2017; HC 383239 DF - publicado em 27.03.2017 e; HC 410990 SP - publicado em 13.11.2017.

Desta forma, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, único regime compatível e que atende ao binômio necessidade/suficiência neste caso, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, em vista da reincidência.

Deixo de substituir a pena do acusado, porquanto não preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, tendo em vista que a pena foi fixada acima de quatro anos e ele é reincidente.

Em que pese a constitucionalidade do previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de determinar a detração neste momento processual, haja vista a ausência de elementos a um seguro decidir quanto ao requisitos subjetivos, situação a ser melhor analisada em sede de execução penal.

A respeito do valor dos dias-multa, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, o réu ALEX PESSOA RODRIGUES, qualificado às fls. 14/15 e 42, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Não se permite ao réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, eis que desfavoráveis as condições subjetivas e presentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, tal qual previsão dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não por outra razão aguardou ao trâmite da instrução encarcerado. Já expedido mandado de prisão em desfavor do réu, expeça-se o ofício de recomendação à prisão em que se encontra.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor do FUNAD.

Com o trânsito em julgado:

- 1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria- Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;
- 2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)
- 3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).

7) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA